

1503209-90.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO ROBERTO ROSARIO JUNIOR

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CLAUDIO ROBERTO ROSARIO JUNIOR, qualificado no inquérito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503209-90.2021.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503209-90.2021.8.26.0510 - 2021/000662

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO ROBERTO ROSARIO JUNIOR

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CLAUDIO ROBERTO ROSARIO JUNIOR, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 07 de outubro de 2.021, por volta das 00:26 horas, na Avenida M 37, altura do nº 1069,

Parque São Jorge, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 120 (cento e vinte) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 32,6 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e laudo de constatação de fls. 19/21, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 17 de fevereiro de 2022. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser majorada em decorrência da recidiva, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, devendo a pena ser cumprida em regime prisional inicial fechado.

Já a ilustre Defensora Pública dizendo insuficiente a prova produzida, no que diz com a posse e a destinação mercantil do entorpecente, requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação pela imputação inicial, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade, inclusive para compensá-la com a agravante da reincidência, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e fixação de regime prisional inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de se facultar a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 70/71, com resultado positivo para cocaína.

Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em Juízo, o acusado negou a prática do delito que lhe é irrogado na denúncia, afirmando que na ocasião dos fatos caminhava pela via pública quando realmente notou a aproximação da viatura policial, em seguida empreendendo fuga, assim porque temeu ser preso, negando tenha neste momento dispensado uma sacola em cujo interior se encontrava o entorpecente descrito na denúncia. Afirmou, ainda, que era constantemente abordado por policiais em via pública, diante de registros que ostentava, desde quando ainda menor, observando que na ocasião dos fatos chegou a sofrer violência no momento em que detido.

Entretanto, a versão deduzida pelo acusado foi contrariada pela prova produzida.

De fato, ouvidos em juízo, e reiterando o que exposto contemporaneamente aos fatos, os Policiais Militares que participaram da abordagem do acusado e apreensão do entorpecente, afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local indicado na inicial, já conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado, tendo este imediatamente empreendido fuga quando notou a aproximação da guarnição, jogando ao solo uma sacola que tinha nas mãos. Diante destas circunstâncias, foi em seguida abordado, com a apreensão da sacola dispensada, em cujo interior foram apreendidas cento e vinte porções de cocaína, divididas em quatro kits de trinta porções cada.

Como se tem consagrado, à míngua de qualquer elemento probatório que indique algum abuso, não se pode presumir que os policiais militares estivessem animados do propósito de incriminar indevidamente o acusado. Sobre isto: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e

fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Como se vê, além da idoneidade dos depoimentos dos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, o acusado ostenta registros relacionados ao comércio ilícito desde quando ainda menor, na prática de atos infracionais equiparados, o que deve ser considerado na compreensão da vida anteacta e também na valoração do que exposto por ele em contraposição ao testemunho prestado pelos Policiais Militares.

Sobre isto, cumpre também observar que a alegada violência policial, sustentando o acusado que teria sido agredido severamente, não encontra apoio no que consta do laudo de exame de corpo de delito de fls. 29/30, constatando-se tão somente pequenas escoriações no ombro esquerdo, compatível com o emprego de força realizada para a detenção do acusado, que na ocasião reconhecidamente empreendeu fuga.

Deste modo, estando o acusado em local conhecido como ponto de venda de entorpecente, tendo empreendido fuga com a aproximação dos policiais e neste momento dispensado uma sacola com cento e vinte porções de cocaína, divididas em kits, tem-se seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial, concorrendo, ademais, em desfavor do acusado a reincidência específica e o longo histórico da prática de atos infracionais assemelhados ao delito que ora lhe é irrogado, equiparado a hediondo.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, não se tratando de quantidade significativa de entorpecente, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de reconhecer a circunstância agravante da reincidência, entendendo preponderar a circunstância da menoridade relativa.

Em face da recidiva, inclusive pela prática do mesmo delito, mas por previsão específica e com efeito diverso, a afastar a objeção de bis in idem, não se mostra possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não bastasse, no exame possível da vida anteacta, mesmo enquanto menor, como se tem reconhecido pelas Instâncias Superiores para esta finalidade, verifica-se que o acusado ostenta registros da prática de atos infracionais equiparados ao tráfico ilícito, a demonstrar que estava efetivamente dedicado à disseminação de entorpecentes.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, artigo 65, inciso I, e artigo 67, todos do Código Penal, CONDENO o acusado CLÁUDIO ROBERTO ROSÁRIO JUNIOR à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, e considerando a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, proferida do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descuidar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de

decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei

P.R.I.C.

Rio Claro, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA